

1504724-22.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Disse que o acusado não se dedicava ao tráfico de drogas, pois trabalhava como barbeiro. Não presenciou os fatos.

Cirlene Aparecida Barbosa Silva é genitora do acusado e disse que o acusado trabalhava como barbeiro, inclusive antes de viver em união com Gabriela. Disse que o acusado não se dedicava ao tráfico de drogas.

Em solo policial, o acusado Carlos Daniel Costa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504724-22.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504724-22.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL COSTA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Carlos Daniel Costa Silva foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 28 de maio de 2021, por volta das 11h00min, na Rua Conchal, nº 106, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiro, 15 (quinze) embalagem contendo a droga cocaína, com peso de 10 gramas, bem como 15 (quinze) pedras da droga "crack", com peso de 3,5 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde).

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 110/123) e a denúncia foi recebida aos 27 de setembro de 2021 pela decisão de fls. 126/127.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado ao final.

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia, afastando-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/06.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do réu,

sustentando que o depoimento dos policiais militares se mostrou contraditório e não pode ser levado em consideração, bem como que a confissão informal realizada pelo increpado é inadmissível. Sustenta que não se dedica ao tráfico de drogas, que o acusado reside nas imediações do local onde foi detido e que a droga apreendida não lhe pertence. Na hipótese de condenação, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III da lei antidrogas. Requer, ainda, a desclassificação de sua conduta e subsunção à figura prevista no art. 28 da lei n. 11.343/06. Sustenta inépcia da denúncia em razão da descrição genérica dos fatos. Requer fixação da pena mínima e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e redução máxima da pena, em razão da previsão do art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de inépcia da denúncia, formulada ao final dos memoriais defensivos, não prospera, na medida em que a inicial acusatória descreve de maneira clara a conduta do acusado e permitiu a perfeita compreensão da imputação atribuída a ele, inclusive com a elaboração de extensos memoriais impugnando a acusação.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 09), pelo laudo pericial do local (fls. 90/95), pelo laudo pericial toxicológico (fls. 84/86 e 87/89) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial militar Ronivei Montefusco disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos e se depararam com o acusado que, ao avistar a viatura, arremessou pedras de 'crack' e porções de cocaína ao solo. O acusado confirmou que se dedicava ao tráfico. Disse que havia outras pessoas do outro lado da rua na ocasião.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar Isaias Daniel Ramalho Vieira, que disse que localizou apenas dinheiro durante a busca pessoal e que as porções de droga foram apreendidas no chão, após terem sido dispensadas pelo acusado.

Gabriela Rodrigues Machado Chamorro disse que foi casada com o acusado, que trabalhava como barbeiro, em um cômodo na casa onde residiam. Nega que o acusado se dedicasse ao tráfico de drogas. Disse que o acusado era usuário de drogas.

Maria Rodrigues Lopes disse que o acusado viveu em união estável com sua filha. Na data do fato, viu os policiais chegando, mas eles não viram a depoente ao lado do acusado. Disse que um dos policiais pediu que a depoente entrasse em casa. O acusado residia na casa da depoente.

Maria de Jesus Cruz disse que mora nas imediações da casa onde o acusado residia. Disse que o acusado não se dedicava ao tráfico de drogas, pois trabalhava como barbeiro. Não presenciou os fatos.

Cirlene Aparecida Barbosa Silva é genitora do acusado e disse que o acusado trabalhava como barbeiro, inclusive antes de viver em união com Gabriela. Disse que o acusado não se dedicava ao tráfico de drogas.

Em solo policial, o acusado Carlos Daniel Costa Silva confessou o comércio de drogas. Afirma que estava no local para vender alguns pinos de cocaína que haviam sobrado do "turno" da madrugada quando foi abordado pelos policiais militares.

Em juízo, o acusado nega a prática descrita pela denúncia. Disse que estava acompanhado de um colega e de sua sogra e que os policiais mandaram que esta entrasse em casa e mandaram seu colega embora. Nega que tenha arremessado as porções de 'crack' e cocaína ao solo. Disse que nunca vendeu drogas e que era usuário de maconha.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais militares é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e diversidade,

tratando-se de 15 porções fracionadas de cocaína e 15 porções fracionadas de 'crack', bem como pela forma como as drogas apreendidas estavam embaladas. Apesar da irresignação defensiva e impugnação ao teor do depoimento prestado pelos policiais militares, ambos disseram claramente que viram o acusado dispensar as porções de cocaína e 'crack' quando a equipe policial se aproximou do local, e eles não teriam motivos para gratuitamente atribuir tal conduta ao acusado, que deixou de comprovar perseguição prévia praticada pelos agentes públicos.

Nem se diga que o acusado cortava o cabelo de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e tal seria o motivo para a perseguição policial, pois se trata de absoluta especulação, sem nenhuma base fático-probatória.

Ainda, a alegação defensiva no sentido de que o acusado não confessou os fatos cai por terra diante da análise rápida do teor do termo de interrogatório de fls. 7, em que o acusado expressamente “confessa a prática ilegal do comércio de drogas (....) que hoje estava pelo local para vender alguns pinos de cocaína que sobraram do turno da madrugada de ontem, quando foi abordado pela Polícia Militar”.

Ora, como se sabe, o fato de o acusado não ter sido acompanhado por advogado naquela ocasião não gera nulidade de nenhuma natureza, em razão da natureza inquisitiva do inquérito policial, sendo certo que competia à defesa arrolar o Delegado e a escrivã de Polícia responsáveis pela confecção daquele termo de interrogatório para confrontá-los quanto ao teor, caso o conteúdo do documento não corresponda à realidade dos fatos.

Ocorre que a defesa não se desincumbiu de tal ônus e, ainda que o acusado tivesse negado a propriedade da droga já em solo policial, o teor do depoimento prestado pelos policiais militares demonstra claramente que ele realmente se dedicava à prática do tráfico de drogas, valendo destacar que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de drogas acondicionadas de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). “Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Inacolhível o pedido desclassificatório formulado em memoriais defensivos, na medida em que o acusado afirmou que era usuário de maconha, mas nenhuma porção desta droga foi apreendida pelos policiais militares, que localizaram 'crack' e cocaína, que foram apreendidas em conhecido ponto de venda de drogas, circunstâncias suficientes para subsumir a conduta do agente à previsão do artigo 33 da lei n. 11.343/06.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, o acusado era menor de 21 anos de idade, devendo ser reconhecida a atenuante, sem reflexo sobre a pena aplicada, pois já estipulada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem estabelecimentos de ensino e praças públicas, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo

infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, deve ser afastada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado, na medida em que, há pouco menos de um mês, o acusado foi preso em flagrante delito pela suposta prática de tráfico de drogas (fls. 167/169), ocasião em que, de acordo com os documentos juntados pelo representante do Ministério Público, teria sido surpreendido na posse de quase 150 porções de maconha, 'crack' e cocaína (autos n. 1500231-95 - fl.167/168).

Nesse caso, cumpre destacar que o acusado respondia ao presente processo em liberdade, na medida em que beneficiado com a liberdade provisória em sede de audiência de custódia, e, apesar disso, teria tornado a se envolver na prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que indica o notório envolvimento do agente em atividades criminosas e impede a aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, que veda a redução da pena do agente que se dedique a atividades criminosas, o que se pode dizer do acusado que, em aproximadamente onze meses, foi preso em duas ocasiões distintas pelo crime de tráfico de drogas.

Em hipótese semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: Embora não se tenha notícia de trânsito em julgado, já foi condenado em outro processo por crime da mesma estirpe, circunstância que, aliada à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, delineia ter a narcotraficância como meio de subsistência. E como a 'mens legis' da redutora foi a de beneficiar o agente que tivesse imerso no submundo do crime em situação de mero desvio de conduta, caracterizando o "marinheiro de primeira viagem", como mencionado pela doutrina, não há como conceder a benesse legal na hipótese. O cenário projetado, portanto, revela fatores sintomáticos da dedicação contumaz do réu ao tráfico de drogas, o que fundamenta o afastamento da benesse legal conferida em primeira instância, reconduzindo a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso (TJSP, Apelação n. 0002956-24.2010.8.26.0362, 4ª Câmara de Direito Criminal Extraordinária, Relator designado Des. Euvaldo Chaib,

julgado aos 7/8/2014).

Nem se diga pela inexistência de sentença condenatória transitada em julgado quanto ao fato ocorrido recentemente, pois o artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, exige que o agente não se dedique a atividades criminosas, não havendo menção à existência de sentença condenatória ou que o envolvimento se refira apenas ao período da maioridade penal, sendo mesmo possível considerar o tempo em que menor de 18 anos de idade para avaliar se o réu faz jus às benesses daquele dispositivo. Assim, ostentando envolvimento em atividades criminosas, o agente não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na seara delitiva, razão pela qual fica afastada a aplicação da minorante mencionada.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

De acordo com o total de pena imposta e porque favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Nesse sentir: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agrado regimental

deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do

tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (tráfico), em razão não somente pela quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. III - Considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agrado regimental desprovido.

(....)

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Na hipótese, verifica-se nos excertos acima colacionados que o v. acórdão impugnado manteve o regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito (tráfico

de drogas), sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da Súmula do STJ, que assim dispõem:

(....)

Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.250 - SP, julgado aos 6/10/2020, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma)

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Carlos Daniel Costa Silva à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá aguardar a análise de eventual recurso em liberdade.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois ausente prova de sua origem lícita e porque se trata de consequência lógica da condenação imposta. Oficie-se após o trânsito em julgado.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 10 de maio de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA